

1501018-18.2019.8.26.0583

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/02/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rafael Antonio Pires Vasconcelos

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

RAFAEL ANTÔNIO PIRES VASCONCELOS, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

3ª Vara Criminal

Avenida Coronel Jose Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente - SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501018-18.2019.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501018-18.2019.8.26.0583

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rafael Antonio Pires Vasconcelos

Juíza de Direito: Dra. Sizara Corral de Arêa Leão Muniz Andrade

VISTOS.

RAFAEL ANTÔNIO PIRES VASCONCELOS, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo

a denúncia, no dia 23 de outubro de 2019, por volta das 19h15, na Rua Oripes Espinhosa, nº 1, cruzamento com a Rua Professor Boulanger, Residencial Anita Tiezzi, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, guardava, sem autorização, para a entrega, ainda que gratuita, ao consumo de terceiros, 140,59g (cento e quarenta gramas e cinquenta e nove centigramas) da substância conhecida como maconha, que contém Tetrahydrocannabinol, constante da Lista F2 da Portaria nº 344/98 da ANVISA.

Segundo narra o Promotor de Justiça, o denunciado mantinha a substância entorpecente enterrada em um pequeno caminho de terra batida, em meio à vegetação rasteira, com a intenção de comercializá-la.

Após receberem notícia de que um indivíduo praticava o tráfico na Vila Real, defronte ao Condomínio Zafira I, policiais militares foram para lá, e posicionaram-se nas imediações de um ponto de venda de drogas.

Depois de algum tempo, viram o acusado saindo do condomínio, cruzando a Rodovia Júlio Budiski e caminhando por uma trilha de terra batida, em meio à vegetação rasteira. Em determinado momento, ele se abaixou e foi abordado.

Em seguida, os milicianos encontraram duas porções grandes de maconha, prontas para serem enterradas.

Argumenta o Ministério Público que as circunstâncias da apreensão denotam a destinação da substância entorpecente à comercialização.

A denúncia (fls. 77/78) veio acompanhada dos autos do inquérito policial (fls. 01/70) e foi recebida em 04 de novembro de 2019 (fls. 98/99).

Citado (fls. 112), o réu, assistido por Defensores nomeados (fls. 123), apresentou resposta à acusação cumulada com pedido de liberdade provisória (fls. 125/129).

Inexistindo questão preliminar a analisar e causa de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi confirmado, indeferindo-se o pedido de liberdade provisória (fls. 135/136).

O acusado constituiu Defensor (fls. 144).

Durante a instrução processual, foi ouvida uma testemunha, seguindo-se o interrogatório do acusado. Os depoimentos foram registrados por gravação audiovisual (fls. 159/160).

Instaurou-se incidente de dependência toxicológica (fls. 159/160).

Reexaminada a presença dos requisitos legais, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, manteve-se a prisão preventiva (fls. 162 e 176/177).

A prisão preventiva foi substituída por outras medidas cautelares (fls. 187/188).

No recurso em sentido estrito nº 0004975-79.2020.8.26.0482, restabeleceu-se a prisão preventiva (fls. 92 daquele apenso).

A presença dos requisitos legais foi reexaminada (art. 316, parágrafo único, CPP) e manteve-se a prisão preventiva (fls. 229/230).

O Defensor apresentou pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 235/247), que foi indeferido (fls. 256/258).

Comunicada a impetração de Habeas Corpus em favor do denunciado e o indeferimento do pedido liminar (fls. 267/270).

O Defensor desistiu da realização do exame de dependência toxicológica (fls. 287) e o pedido foi homologado (fls. 145 do incidente processual nº 0000717-26.2020.8.26.0482).

Nas alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação, nos moldes da denúncia (fls. 297/306).

O Defensor, preliminarmente, alegou nulidade do processo, por cerceamento de defesa, decorrente da ausência de exames papiloscópico e de dependência toxicológica. No mérito, postulou a absolvição, alegando a insuficiência da prova colhida para embasar decisão condenatória. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06; pela fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade; e pela substituição dessa por restritiva de direitos (fls. 309/332).

Reexaminada a presença dos requisitos legais, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, manteve-se a prisão preventiva (fls. 339/340).

Noticiada a incineração dos invólucros da substância entorpecente (fls. 347),

manifestaram-se o Ministério Público (fls. 367) e o Defensor (fls. 368/370).

É o relatório.

DECIDO.

Considerando a notícia de incineração dos invólucros da substância entorpecente (fls. 347), fica prejudicada a produção da prova deferida às fls. 66, item 2. Não houve cerceamento de defesa.

Conforme se expôs no relatório, o Defensor desistiu da realização do exame de dependência toxicológica (fls. 287).

Como a ausência de produção da prova decorreu de pedido expresso do Defensor, não houve cerceamento ao exercício do direito de defesa.

Analiso a adução de nulidade, em razão da ausência de submissão dos invólucros a exame pericial papiloscópico.

A realização do exame em questão foi determinada pelo juízo (fls. 66), mas a produção da prova restou inviabilizada, pela incineração do objeto material (fls. 347).

A princípio, a ausência de submissão do vestígio a perícia implicaria nulidade, consoante previsão contida no artigo 564, inciso III, alínea b, do Código de Processo Penal.

Todavia, o artigo 563 do Código de Processo Penal estabelece que Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

No caso, o prejuízo que poderia advir à defesa em razão da ausência da perícia seria a impossibilidade de demonstrar que os invólucros não tinham, em si, impressões dígito-papilares do acusado.

Contudo, em decorrência do princípio da presunção de não culpabilidade, a ausência da prova por desídia estatal acarreta efeito contrário, pois implica presunção de que as impressões dígito-pilares do acusado não estavam no objeto que seria submetido a exame.

Para que não emergja prejuízo ao denunciado, no exame do conjunto probatório considerar-se-á demonstrado aquele fato. Ou seja, no exame do conjunto de provas, considerar-se-á como demonstrado que as impressões dígito-papilares do acusado não estavam sobre os invólucros.

Lembre-se que a produção probatória não é um fim em si, mas instrumento para a formação da convicção do julgador. Leia-se:

Prova é o conjunto de elementos produzidos pelas partes ou determinados pelo juiz visando à formação do convencimento quanto a atos, fatos e circunstâncias. Conforme refere Guilherme de Souza Nucci, o termo prova deriva do latim probatio, que significa ensaio, verificação, inspeção, exame, argumento, razão, aprovação ou confirmação.

No processo penal, a produção da prova objetiva auxiliar na formação do convencimento do juiz quanto à veracidade das afirmações das partes em juízo. Não se destina, portanto, às partes que a produzem ou requerem, mas ao magistrado, possibilitando, destarte, o julgamento de procedência ou improcedência da ação penal.

Correto, neste sentido, o ensinamento de Mirabete quando refere que “provar é produzir um estado de certeza, na consciência e mente do juiz, para sua convicção, a respeito da existência ou inexistência de um fato, ou da verdade ou falsidade de uma afirmação sobre uma situação de fato que se considera de interesse para uma decisão judicial ou a solução de um processo” (Avena, Norberto Cláudio Pâncaro, Processo penal: esquematizado, 6.^a ed., São Paulo: Método, 2014, p. 727).

Portanto, atingida a finalidade de demonstrar que as impressões dígito-pilares do acusado não estavam no objeto, ainda que por presunção, não se vislumbra prejuízo. A ausência de prejuízo ao réu implica ausência de nulidade, consoante dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal.

No mais, o processo está em ordem. Não há irregularidade ou nulidade a sanar e estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal. Impõe-se, portanto, o julgamento do mérito.

A materialidade do crime de tráfico de drogas ficou demonstrada por meio dos autos de prisão em flagrante delito (fls. 01/07) e de exibição e apreensão (fls. 11), do

laudo de exame químico toxicológico (fls. 14/16) e da prova oral, colhida sob o contraditório.

A prova oral também revelou a autoria da infração penal.

Vejam os o conjunto probatório.

O laudo de exame químico toxicológico (fls. 14/16) demonstra a natureza entorpecente da substância apreendida, que contém Tetrahydrocannabinol em sua composição.

Não há dúvida de que a droga se destinava ao fornecimento a terceiros, haja vista sua grande quantidade, que seria suficiente para confeccionar mais de uma centena de papé debates individuais.

Nesse sentido são esclarecedores os casos objetos dos julgados a seguir, nos quais cada porção individual da substância entorpecente pesava, em média, 0,912g

(novecentos e doze miligramas) e 0,91g (noventa e um centigramas), respectivamente:

(...) trazia consigo 58 invólucros plásticos contendo cocaína, com peso de 45,8 gramas, 48 invólucros plásticos contendo maconha, pesando 43,8 gramas e 18

invólucros plásticos contendo crack, com peso de 4,7 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...). (TJSP; 16ª Câmara Criminal; Apelação nº 990081469807; Relator: Desembargador Pedro Menin; j. 13/04/2010).

(...) trazer consigo, para consumo de terceiros, 91g (noventa e um gramas) de "maconha", dispostos em cem papé debates plásticos, 42g (quarenta e dois gramas) de "cocaína", acondicionados em quarenta e dois supositórios plásticos, e 7,8g (sete gramas e oito decigramas) de "crack", acondicionados em trinta invólucros de papel

alumínio, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...). (TJSP; 36ª Câmara Criminal; Apelação nº 990093256975; Relator: Desembargador Toloza Neto; j. 25/05/2010).

Resta verificar se as porções de maconha estavam sob a posse do denunciado. Interrogado (fls. 159/160), o réu negou a prática do crime. Disse que policiais

estiveram em sua casa no dia anterior à prisão, conversaram com sua esposa e afirmaram que o interrogado estava comercializando substâncias entorpecentes. Na data do fato, trabalhara durante o dia e retornara para sua moradia. Por volta das 19h00, saiu para comprar pão, deixou a área do condomínio e ingressou em uma trilha de terra batida, que era o único caminho de acesso à padaria. Enquanto passava pela trilha, teve vontade de evacuar e decidiu voltar para sua residência. Quando retornava, foi abordado por policiais, os quais disseram que o interrogado arremessara algo. Explicou-lhes que saíra para comprar pão, mas decidira voltar para casa, para evacuar. Outra viatura chegou ao local e os policiais passaram a procurar drogas pela vegetação. Quando a equipe de canil chegou, continuaram as buscas. Disse que não viu substância entorpecente sob a posse dos policiais. Disse considerar que seria necessário exame papiloscópico para demonstrar que a substância entorpecente estava sob a sua posse.

Conforme se expôs anteriormente, presume-se que as impressões dígito-papilares do denunciado não estavam nos invólucros. Apesar disso, não há dúvida de que a droga estava sob a posse Rafael Antônio.

A ausência de impressões dígito-papilares não é prova irretorquível da inexistência de contato físico entre um indivíduo e um objeto, pois a fixação das impressões depende de fatores como a qualidade da superfície e contato com áreas suficientes das faces internas das últimas falanges dos dedos.

Portanto, outros elementos de prova podem evidenciar que o objeto estava sob a posse do agente, ainda que a peça não contenha as impressões dígito-papilares dele. No caso, a adução do réu, de que deu meia volta por premência fisiológica não é minimamente factível, pois saíra de casa havia poucos instantes.

A declaração de que trabalhara na data do fato não foi secundada por prova alguma. Além disso, a testemunha Renato Trombeta Marochio informou que viu o denunciado se abaixando no local do fato e encontrou as porções de maconha aos pés dele.

A testemunha Renato Trombeta Marochio (fls. 159/160), policial militar, informou que, previamente aos fatos, vários transeuntes noticiaram que um indivíduo estava praticando o tráfico de drogas nos fundos da Vila Real. Na data do fato, foram à Rua Oripes Espinhosa, no final daquele bairro, e posicionaram-se, aguardando que

alguém passasse por lá. De onde estavam, viram o denunciado saindo do condomínio Zafira, atravessando a rodovia e ingressando em uma rua de terra batida, em direção à Rua Oripes Espinhosa. Em determinado ponto do caminho, viram-no se abaixando, aparentemente para pegar ou enterrar algo em um terreno. Em seguida, abordaram-no e encontraram duas porções de substância entorpecente aos seus pés. Como recearam que fugisse, algemaram-no, deram voz de prisão e puseram-no no guarda presos. Embora houvesse informação e que havia mais droga por perto, realizaram buscas com cão farejador e nada encontraram.

Inexistem indícios de que a testemunha tenha mentido, tampouco de que possua motivos para tanto.

Ao contrário do alegado pelo Defensor, a condição profissional da testemunha não diminui a fiabilidade de suas declarações se não houver indícios concretos de que tenha mentido. Neste sentido:

(...) O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça (...). (STJ; Quinta Turma; AgRg no AREsp 739749/RS; Relator: Ministro Jorge Mussi; j. 19.05.2016).

Aliás, carece de lógica investir alguém no exercício de função pública e, depois, negar credibilidade, antecipadamente, ao relato que venha a prestar de sua atividade oficial. O depoimento policial só se torna suspeito de parcialidade, se resultar demonstrado algum interesse particular seu na investigação ou desvio de conduta, na espécie inócua. (TJSP; Apelação nº 1367.071/2; 14ª Câmara Criminal, Relator: Desembargador René Ricupero; proferida em 30/09/2003).

Não é crível que os policiais acionassem outras equipes, como descreveu o réu, para simular a posse de drogas que, supostamente, já tinham à mão.

Além do mais, o agachamento visualizado pela testemunha e o encontro das porções de maconha aos pés do réu revelam que as porções de maconha estavam sob a posse dele, estivesse ele a buscá-las ou a levá-las.

Ao ter consigo e guardar substância entorpecente destinada ao fornecimento a terceiros, o acusado praticou condutas previstas no caput do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Por estar demonstrada a destinação da droga ao fornecimento a terceiros, fica logicamente afastada a possibilidade de desclassificar a conduta para a prevista no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Como o réu ostenta maus antecedentes e é reincidente, não está configurada a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Demonstradas, pois, a materialidade delitiva e a autoria da conduta e ausentes excludentes da ilicitude, dirimentes da culpabilidade ou hipóteses de não aplicação da pena, é caso de condenação do réu às sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

Em respeito aos artigos 59 e 68 do Código Penal e ao artigo 42 da Lei nº 11.343/06, observo que o réu possui maus antecedentes, consistentes nas condenações nos processos de conhecimento nº 0009646-03.2010.8.26.0481 (fls. 46), 0017452-86.2010.8.26.0482 (fls. 48) e 0026907-12.2009.8.26.0482 (fls. 49).

Não há notícias desabonadoras sobre sua conduta social, tampouco informações confiáveis sobre a sua personalidade e a motivação para a prática delitiva.

Sua culpabilidade (entendida como o índice de reprovabilidade de sua conduta), as circunstâncias e as consequências da conduta não fogem do corriqueiro para esta espécie de crime.

Considerando a circunstância judicial desfavorável, aplica-se a pena-base com exasperação de 1/6 (um sexto) sobre o patamar mínimo, seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por inexistirem informações seguras sobre as condições econômicas do denunciado, fixo o valor unitário do dia-multa no mínimo legal.

Na segunda etapa do cálculo das penas, verifico que o acusado é reincidente (art. 61, I, CP), pois voltou a praticar crime após a condenação no processo de conhecimento nº 0028425-90.2016.8.26.0482 (fls. 49).

Por conseguinte, agravam-se as sanções em 1/6 (um sexto), passando-as para 06

(seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Na terceira fase do cálculo, não está presente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pois o réu é reincidente e possui maus antecedentes.

Considerando a reincidência e os maus antecedentes, o denunciado deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime fechado (art. 33, §§ 2º e 3º, CP).

Por não estarem preenchidos requisitos subjetivos (reincidência e maus antecedentes) e objetivo (quantum da sanção), são incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, CP) e a concessão de sursis (art. 77, CP).

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar RAFAEL ANTÔNIO PIRES VASCONCELOS, nascido aos 29/01/1991, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Neusa Aparecida Pires Vasconcelos e de Aparecido Bezerra de Vasconcelos, inscrito no Registro Geral nº 41.157.289-5 SSP/SP e no CPF nº 427.545.838-90, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a cumprir pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e a pagar 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, calculado o dia-multa no valor unitário mínimo, atualizado.

A reincidência e os maus antecedentes denotam o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, decorrente do risco de reiteração. Tal circunstância determina a manutenção da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, CPP), para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, além do indeferimento do direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu no estabelecimento prisional em que se encontra.

Condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, ressaltando-se que a cobrança ficará condicionada à melhora de suas condições econômicas nos próximos cinco anos.

Ausente divergência relativa à natureza entorpecente da substância apreendida e sua quantidade, autorizo a destruição imediata da droga mantida sob a custódia da Autoridade Policial. Oficie-se.

Para controle, anoto que o réu está assistido por Defensor constituído (fls. 144). Transitada em julgado, expeça-se guia de recolhimento, intime-se para pagamento da multa, e façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial e comunicações ao IIRGD e à Justiça Eleitoral. Oportunamente, arquivem-se os autos. P.I.C.

Presidente Prudente, 20 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA